

1512163-35.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/06/2022

... si só, não é suficiente a caracterizar o crime de tráfico. No entanto, o montante e variedade de drogas apreendidas em poder do réu, não deixam dúvidas que serviam para o tráfico de drogas, eis que a quantidade apreendida, na circunstância, mostra-se absolutamente incompatível com o uso próprio.

Tanto é assim que os policiais militares responsáveis pela prisão do réu, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1512163-35.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512163-35.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2137965/2020 - 85º Distrito Policial - Jardim Mirna, 1543/2020 - 85º Distrito Policial - Jardim Mirna

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO APARECIDO FERREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Processo nº 869/20

VISTOS.

RODRIGO APARECIDO FERREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado por infração ao disposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, c.c. 61, II, 'j', do Código Penal; porque consta, que no dia 05 de junho de 2020, por volta de 16h, em ocasião de calamidade pública 1, à rua Projetada, 100, Grajaú, São Paulo, trazia consigo, para consumo de terceiros, cerca de 8.3g de cocaína, 131g de Cannabis sativa L, 10.7g de cocaína na forma de crack e 1.1g de Metanfetamina, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida à fl. 69.

Suspensão do processo e do prazo prescricional com fulcro no artigo 366 do Código de Processo Penal, fls. 95. Revogada a suspensão diante da prisão e citação pessoal

do réu, fls. 107.

Foi apresentada defesa preliminar à fl. 112.

Durante a instrução processual, foram ouvidas através do sistema de áudio e vídeo, duas testemunhas de acusação, e o réu foi interrogado.

Em debates, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos exatos termos da denúncia por entender bem demonstradas autoria e materialidade do crime.

A defesa, por seu turno, requereu a absolvição do réu pela ausência de provas suficientes para condenação. Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento da minorante, a pena no mínimo, regime mais brando e direito de recurso em liberdade. É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva veio comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09, dando conta dos 17 invólucros de Cocaína; dos 50 invólucros de Maconha, dos 34 de Crack, dos 03 comprimidos de Ecstasy, além da quantia de R\$ 25,00, localizados e apreendidos em poder do réu.

Em complementação, o laudo químico toxicológico de fls. 126/129, atestou que as substâncias apreendidas eram positivas para tetrahydrocannabinol, cocaína e metilenodioximetanfetamina.

A autoria também é inconteste.

De fato, os argumentos da douta Defensoria Pública não foram suficientes para ilidir os fortes indícios e as provas diretas contra ele derivadas, em especial, pelas testemunhas inquiridas e declarações do próprio increpado que nada de exculpatório trouxe aos autos.

Na Delegacia de Polícia o réu negou a traficância, alegando que é usuário e tinha ido até o local apenas para comprar droga pra usar. Relata que quando da abordagem dos policiais, permaneceu parado diante da ordem enquanto os outros indivíduos correram, que ficou cerca de 20 minutos detido por um policial enquanto outros procuraram a droga dispensada pelos traficantes de verdade e ao a acharem no mato, trouxeram e disseram que era sua, fls. 05.

Em Juízo, sob o crivo do contraditório, o réu forneceu sua versão dizendo que no dia dos fatos, eu fui numa pizzaria ali próximo. Nessa época eu morava na rua, e peguei panfletos para fazer panfletagem. Eu sou usuário de cocaína e ia comprar com os 30 reais que eu tinha. Quando eu entreguei o dinheiro, os meninos gritaram, molhou molhou, e começaram a correr. Como eu não tinha nada, não corri. Fui abordado, disse aos policiais que estava ali para comprar drogas, e mostrei o dinheiro para eles. eles me liberaram, até que veio um outro policial, me abordou novamente com essa bolsa e disse que a droga era minha. Eu ainda argumentei que eu não sou traficante, tanto que estava mal vestido. Eu não sou traficante, sou dependente químico. Eu fui preso no poupa tempo, tirando meu RG. Não conhecia os policiais.

Ocorre porém que os argumentos do acusado não encontraram respaldo nas demais provas dos autos, motivo pelo qual, não convenceu. O réu não apresentou qualquer versão plausível para sua prisão. Limitou-se a dizer o que todos dizem quando são surpreendidos em poder de grande quantidade de drogas ou seja, que estava apenas passando quando foi abordado, os traficantes fugiram, e acabou sendo detido.

No entanto, não se pode acreditar que os policiais deixassem os verdadeiros traficantes fugirem, e do nada, resolvessem prender o réu, e acusa-lo da prática de um crime de tamanha gravidade, não tivesse efetivamente participação no crime em voga. Ainda mais quando as partes são desconhecidas, como no presente caso e não há uma evidência sequer a revelar que a acusação pudesse ter por fundamento apenas vingança ou outro motivo qualquer.

Não há como se acreditar que os policiais resolvessem amealhar entorpecentes e dinheiro, em local diverso, colocando-os a disposição dos autos e da Justiça, apenas para acusar o réu da prática do tráfico de drogas, no afã de vê-lo condenado. Tanto que o próprio réu, em seu interrogatório, afirmou que não conhecia os policiais.

Mesmo porque, não se pode crer que o réu estivesse com tamanha quantidade e variedade de drogas em seu poder, não fosse para o exercício da traficância. Desta forma, não se tem nos autos, um indício sequer que pudesse evidenciar que toda a prova acusatória tivesse sido produzida com a finalidade única de prejudicar o réu ou mesmo acusá-lo falsamente. Ainda mais quando as partes são desconhecidas, como no presente caso.

É certo que a quantidade da droga por si só, não é suficiente a caracterizar o crime de tráfico. No entanto, o montante e variedade de drogas apreendidas em poder do réu, não deixam dúvidas que serviam para o tráfico de drogas, eis que a quantidade apreendida, na circunstância, mostra-se absolutamente incompatível com o uso próprio.

Tanto é assim que os policiais militares responsáveis pela prisão do réu, Gabriel Gezarano e Mateus Fossaluzza Teixeira, ouvidos em Juízo, relataram de forma firme, segura, e em uma só voz que estávamos em patrulhamento pelo local dos fatos, onde há grande prática de tráfico de drogas. Desembarcamos da viatura, e fizemos uma incursão a pé. Vários indivíduos correram, mas o réu acabou sendo detido em poder da sacola, no interior da qual estavam as drogas e o dinheiro. O réu disse que era usuário e estava no local apenas para usar drogas. Reconheceram o réu e não o conheciam anteriormente. O réu estava segurando a sacola quando foi detido.

Os policiais militares narraram com segurança e precisão como se deu a prisão do acusado, relatando todos os detalhes, desde patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico, o momento em que visualizaram um grupo de pessoas sendo que uma delas segurava uma sacola, perseguição, a detenção do réu, sua revista e encontro das drogas e dinheiro no interior da sacola, até final prisão.

Mister se faz, neste momento, dizer que o testemunho dos policiais deve ser valorado como de qualquer outra pessoa, não havendo motivo para de pronto depreciá-lo. Há muito já se encontra superado o entendimento de que a fala policial não se prestaria como elemento probatório.

No sentido já se manifestou o STF, quando do julgamento do HC 76.557-RJ, 2ªT., rel. Carlos Velloso, 04.08.1998: "O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento."

E ainda: "Como servidores públicos que são, os agentes policiais têm, no exercício de suas funções, a presunção juris tantum de que agem escorreitamente, não estando impedidos de depor sobre os atos de ofício de cuja fase policial tenham participado" (TJ/SP, Ap. 287.216-3, 3ª C., rel. Segurado Braz, 27.01.00).

Além disso, o depoimento dos policiais foi tranquilo, harmonioso e revelou sincronia lógica. Narraram a situação com firmeza, descrevendo as diligências sem qualquer mácula ou eiva de vício a contaminar a prova. Não houve contradição na parte substancial do que disseram na fase policial e em Juízo e eventuais discrepâncias existentes em seus depoimentos, são normais aos relatos prestados por qualquer ser humano, e em nada abalam a condenação.

Tanto é assim que a jurisprudência afirma: "As pequenas contradições decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas pelas condições em que a prova é realizada. O testemunho demasiado perfeito, esse, sim é que deve gerar desconfiança" (TACRIM-SP-AP- Rel. Nelson da Fonseca - JUTACRIM-SP 67/311).

Tal a circunstância dos autos. A fala das testemunhas mostrou-se coerente, repita-se e firme desde a fase inquisitiva, narrando com clareza o discorrer dos fatos. Em que pesem, pois, os argumentos da defesa, alegando em síntese que tudo não passou de uma armação para incriminar o réu e que os policiais não lograram êxito na prova da traficância, vejo nos autos que todas as circunstâncias apontam em sentido contrário.

Neste contexto, em vista da grande quantidade de drogas encontradas em poder do réu, e ainda o relato seguro e firme por parte dos policiais, resta inexoravelmente comprovado que mantinha substância tóxica para consumo e entrega a terceiros.

Nem se cogite que a ausência de descrição de ato de venda, compra ou qualquer outro que indicasse atividade de mercância, pudesse vir a inocentar o acusado da

imputação descrita na denúncia. E isso porque, tratando-se de tipo penal tido como de conteúdo múltiplo ou variado, preencheu o réu um dos núcleos do tipo denunciado, sendo pois, impossível a absolvição. Para a condenação, na hipótese dos autos, é absolutamente irrelevante não ter o agente, sido surpreendido no ato da venda, bastando que haja indicativos outros, como forma de acondicionamento da droga e respectiva quantidade, a indicar a finalidade do tráfico.

No sentido: "Pretendida a desclassificação do art. 12 para o art. 16 da Lei 6368/76 - Inadmissibilidade - Prova robusta no sentido de tipificar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes - Irrelevante não ter o apelante sido surpreendido no ato da venda - Forma de acondicionamento da droga em invólucros indicativos de fim de mercancia - Recurso não provido. (Ap. 296.182-3, São Paulo, 4ª C., rel. Canellas de Godoy, 25.04.2000, v.u.).

O fato do réu ser também usuário e estar vendendo para sustentar seu vício, em nada abala a tipificação constante na denúncia. Os chamados traficantes usuários devem ser penalizados, com o mesmo rigor, uma vez que integram a cadeia do tráfico de forma fundamental, pois com o objetivo de conseguirem lucro fácil para sustentarem seus vícios, assumem todos e quaisquer riscos a fim de aliciarem novos clientes e usuários. Destarte, não evidenciou-se qualquer situação que pudesse excluir o crime ou isentar o réu da pena.

Em arremate, não há que se falar na incidência da agravante referente à calamidade pública, tendo em vista que a pandemia que assola a população mundial, em nada afeta os fatos ora tratados nestes autos. Observo que o crime não sofre qualquer influência pela atual situação pandêmica, ao menos nada há nos autos que comprove o contrário. Nesta esteira de raciocínio, a agravante postulada pelo representante do ministério público há que ser afastada.

Passo a dosar a pena.

Verificando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, atento dolo normal à espécie.

O acusado é primário, e não ostenta antecedentes criminais, de maneira que fixo a pena base no mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na hipótese dos autos, forçoso de faz reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei de Tóxicos. E isso porque o acusado primário, sem quaisquer antecedentes, é jovem e não há um indício sequer a demonstrar que faça parte de alguma organização criminosa.

Assim, considerando-se a capacidade lesiva de uma das drogas em questão, tratando-se de crack, reduzo a pena base em 1/3, perfazendo 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa. Sobre o tema, já assentou o Colendo Superior Tribunal de Justiça que "O art. 42 da Lei nº 11.343/06 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base, quanto na determinação do grau de redução da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da nova lei de Tóxicos. Na hipótese, à luz do art. 42 da lei 11.343/2006, a natureza da substância entorpecente apreendida - 13 (treze) pedras de crack - justifica a não aplicação do redutor em seu grau máximo, qual seja: 2/3" (5ª T., HC 225.575/ES, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Dje 05/06/2012). O valor do dia multa é o mínimo legal.

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação penal, para condenar RODRIGO APARECIDO FERREIRA, como incurso nas penas do artigo 33, §4º da Lei nº11.343/06, a cumprir, em regime inicialmente aberto, a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Na hipótese específica destes autos, o regime aberto se justifica tendo em vista que o réu é primário, sem qualquer mácula em sua vida, foi solto no curso do processo, sendo que somente foi novamente preso por não ter cumprido as condições impostas por ocasião da liberdade provisória.

De outro giro, não é possível a aplicação de qualquer substituição, porque o escopo

do legislador foi beneficiar delitos que não mantêm repercussão na sociedade, o que não é o caso do tráfico de drogas, cujo promovente deve ser segregado do convívio social. Não se pode perder de vista ainda, que o artigo 33, §4º da Lei de Tóxicos prevê, de forma expressa a vedação da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

É certo que o STF, nos autos do HC 97256/RS, cujo relator foi o Ministro Carlos Ayres Brito, declarou de forma incidental a inconstitucionalidade da vedação em apreço. Mas é certo também que referida decisão foi proferida por maioria apertada (6x4) e reconhecida, apenas na hipótese específica daqueles autos, alcançando tão somente, as partes que ali figuraram.

No mesmo sentido, foi a recente decisão proferida pela 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Apelação nº 0090150-57.2012.8.26.0050, cujo teor passo a descrever: "Como bem colocado pelo Ilustre Desembargador Souza Nery: "inviável a aplicação da pena alternativa. Não só pela própria hediondez do crime, que recomenda maior rigor no escarmento, mas também porque a Lei nº 11.343/06 expressamente veda a benesse aos traficantes, nos precisos termos do que dispõe o seu artigo 44, caput. Tal dispositivo legal foi editado pelos poderes competentes, goza de presunção de constitucionalidade e não parece ofender a Constituição de República de modo franco e direto. Não desconheço que foi reconhecida a inconstitucionalidade desse dispositivo pelo Excelso Pretório (HC 97.256) no ano de 2010, mas essa decisão foi tomada por maioria apertada (6 x 4) e valeu somente para o processo julgado (incidenter tantum)."

Desta forma, não há qualquer declaração de inconstitucionalidade erga omnes, de maneira que, em cada caso concreto, a vedação imposta pela Lei de Tóxicos, pode ser aplicada e reconhecida.

Oficie-se à autoridade policial, oportunamente, para incineração do entorpecente apreendido, nos termos do artigo 72 da Lei 11.343/06.

Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do réu.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 21 de junho de 2022.

EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Juiza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA